

プラットフォーム事業者の 流通情報の管理を通じた表現の自由

海野 敦史

プラットフォーム事業者によるアルゴリズム利用情報管理

プラットフォーム事業者

- ・ ネットワーク空間上（インターネット上）で各種プラットフォームを運営する事業者。
- ・ 特に、ソーシャルメディアをはじめ、不特定の者が発信（表出）する情報を不特定の者が閲覧可能な基盤を利用可能とする役務を提供する者をここでは念頭におく。

問題意識

- ・ 近年、偽情報の取扱いのように、発信者の権利を保障する観点から法律上の強固な規制になじまない領域において、プラットフォーム事業者の積極的な取組に対する期待が世界的に高まっている。
- ・ プラットフォーム事業者においても、プラットフォームの適切な維持管理の観点から、キーワード等を手がかりとした一定のアルゴリズムに依存する機械的な処理（**アルゴリズム利用情報管理**）を広く実施。
- ・ アルゴリズム利用情報管理がそれ自体として憲法21条1項の規定に基づく表現の自由として保障されるのか、保障されるのであればどの程度の保障を受けるのか。

アルゴリズム利用情報管理の主な懸念要素

「私的検閲」のおそれ

- ・ 政府による事前規制に極めて慎重であった表現の自由の伝統に背馳する可能性。

利用者間の「差別」を助長するおそれ

- ・ アルゴリズム利用情報管理のあり方に合わせて自らの行動を調整し、差別的な取扱いから逃れようとする利用者側のインセンティブを惹起する可能性。

個人の自律を阻害するおそれ

- ・ 流通情報のパーソナライズ化を促進し、個々の利用者が自ら嗜好する情報へのアクセスを強化・集中させることにより、意見等を同じくする集団の分極化が進み、その影響を受けた個人の自己決定のあり方をも変え、その自律を脅かす可能性。

言論としてのアルゴリズム利用情報管理の自由をめぐる米国法上の議論(Ⅰ)

米国憲法修正 1 条

- ・ 連邦議会は、国教を樹立するための法律、宗教上の行為を自由に行うことを禁止する法律、**言論**又は**プレス**の**自由**及び市民が平穏に集会する権利並びに苦情の処理を求めて政府に請願する権利**を制限する法律を制定してはならない**。

機械処理説

- ・ アルゴリズム利用情報管理は機械による処理であり、アルゴリズムの作成者の思想を伝達することを予定したものではないため、基本的に修正 1 条との関係で問題とならないとする考え方。
- ・ アルゴリズム利用情報管理は機能的な情報の処理を行うにすぎないという点に着目しつつ、これがプラットフォーム事業者の言論であることを実質的に否定。

【批判】

- ・ 当該処理の過程で人の考え等が示され得ることを無視。
- ・ アルゴリズムによる判断も何をどのように利用者に示すかといった点に関する事業者の見解の反映と捉え得る。

言論としてのアルゴリズム利用情報管理の自由をめぐる米国法上の議論(2)

介入禁止説

- ・プラットフォームが情報のやり取りで基幹的な役割を担っていることを踏まえ、言論者が自らの言論を受領者に行き渡らせることを妨げるプラットフォーム事業者の介入は基本的に禁止されるところとする考え方。
- ・プラットフォーム事業者の（アルゴリズム利用情報管理を通じた）言論の自由は皆無ではなく、利用者を適切に保護する観点から、アルゴリズム利用情報管理に対する規制が修正1条との関係上問題となる場合があり得るとの思想。

※ 任意のアルゴリズム利用情報管理に対する規制は言論内容中立規制として位置づけ。

【批判】

- ・プラットフォーム事業者自身の言論の自由が軽視されている。
- ・媒体の種類にかかわらず言論は保護されるべき。

公益事業説

- ・SNS等のプラットフォームを運営する事業者の公的な性格ないし公益事業者としての性質に照らし、アルゴリズム利用情報管理を通じた言論の自由は本質的に著しく制約され、差別的取扱いの禁止等の法令上の義務を負うという考え方。

言論としてのアルゴリズム利用情報管理の自由をめぐる米国法上の議論(3)

- ・ 米国政府（民主党政権）がインターネット接続役務提供者に対して「ネットワークの中立性」に関する行為規範（流通情報に対する不当な遮断行為の禁止等）を及ぼそうとしたことと同様に、プラットフォーム事業者にもその言論の自由に対する強度な制約となる行為規範が及ぶべきであるとの思想。

【批判】

- ・ ソーシャルメディア等の管理権能はネットワークの管理権能と比べてより競争的である実態等を軽視。

支配者説

- ・ プラットフォーム事業者がプラットフォーム上のコミュニティの「支配者」とであると捉えつつ、アルゴリズム利用情報管理の実施に際して設定されるルールとともに、それに対する政府による一定の統制が重要となるという考え方。
- ・ 公益事業説と異なり、プラットフォーム事業者をインターネット接続役務提供者と同視するものではなく、当該事業者の広範な言論の自由（アルゴリズム利用情報管理を通じた「言論差配」の余地）を肯定し、その行使に際しての具体的な方針の適正性や策定手続の透明性等を重視する思想。

言論としてのアルゴリズム利用情報管理の自由をめぐる米国法上の議論(4)

- ・ 支配者説の観点からは、今日の言論の自由については、公権力と各人との二面的な関係ではなく、公権力、支配者としてのプラットフォーム事業者等及び各利用者という三面的な関係で捉えるべきであるとする主張も。

マスメディア区別説

- ・ 「マスメディアの言論の自由」との並びでプラットフォーム事業者の言論の自由を一応肯定しつつも、アルゴリズム利用情報管理を伝統的なマスメディアの編集機能と区別する考え方。
- ・ プラットフォーム事業者は、一般に積極的に特定の情報を求めるわけではなく、他人が発信する情報の「共有」を可能とするための環境を提供するにすぎないことから、伝統的なマスメディアよりも言論の主体としての地位が弱いという思想。
- ・ 伝統的なマスメディアが編集権を行使する前提として、新聞等に掲載される言論を自ら承認するのに対し、アルゴリズム利用情報管理はプラットフォーム上の言論を必ずしも承認するわけではないという相違点も前提。

アルゴリズム機能区別説

- ・アルゴリズム利用情報管理について、利用者の言論（表現物）をその内容に応じてふり分けるための管理（**言論選別型管理**）と、情報の配置・検索等のための管理（**情報配置検索型管理**）とを規範的に区別する考え方。
- ・修正1条に基づく「編集権」を保障する観点から、言論選別型管理に対する規制は十分に調整されたものでなければならないのに対し、情報配置検索型管理に対する規制はその限りではないという思想。
- ・思想の自由市場に対する最大の脅威は言論の事前規制であったが、今日では、ある言論を抑圧する実効的なツールは大量の言論をネットワーク空間に放ち、受領者に言論を「選別」する手間暇をかけさせることである中で、言論選別型管理は、この選別の過程を支援しつつ、各人の言論の自由を「取り戻す」ことに資する効果（**選別支援効果**）を有するため、みだりに制約されることになじまないという前提。
- ・情報配置検索型管理については、情報の処理過程で特定の見解が示されるものではないことから、営利的言論に近似し、それが言論として保護される程度についても、営利的言論規制が許容される程度に関する比較的緩やかな判断に近接するという前提。

表現としてのアルゴリズム利用情報管理の憲法上の保護（Ⅰ）

表現性三要件

- ・ 表出型行為性
- ・ 個別的伝達・理解可能性
- ・ 表出内容の実体性

アルゴリズム利用情報管理の表現性

- ・ アルゴリズム利用情報管理において、アルゴリズムの作成者はプラットフォーム事業者（又はその委託等を受けた者）。
- ・ プラットフォーム事業者自身が、自らが支配するプラットフォーム上における流通情報について、それをどのように配置し、又はどの情報を存置、保存等させるかということに関する一定のメッセージを（情報の表示・不表示等を通じて）対外的に示す行為。
- ・ その行為の前提として、流通情報等の取扱いに関する利用規約等が各人に示され、利用者はその規約等の内容を承諾したうえでプラットフォームを利用することが一般的。
- ・ それゆえ、プラットフォーム事業者の個別的かつ実体的なメッセージが伝達されるもので、利用者はそれを理解可能であると考えられるため、「表現」とであると認められる。
⇒機械処理説は援用不可。

表現としてのアルゴリズム利用情報管理の憲法上の保護(2)

米国の学説の援用可能性に関する検討

- ・ 介入禁止説及び公益事業説については、アルゴリズム利用情報管理を通じたプラットフォーム事業者自身の表現の自由の行使を実質的にほぼ許容しないという点で共通する。
- ・ これらの学説からは、「アルゴリズム利用情報管理を行うプラットフォーム事業者は、（電気通信事業者とともに）厳格な規律に服することが予定され、その表現の自由は内在的に大幅に制約される」という解釈も。
- ・ しかし、電気通信事業者とプラットフォーム事業者との機能的な相違に着目すべき。すなわち、電気通信事業者は憲法21条2項後段の規定が予定する「通信」の成立に不可欠となる伝送行為を担い、「通信の秘密」を取り扱うため、厳格な行為規範に服することが憲法上予定されている。
- ・ 一方、多くのプラットフォーム事業者は、自らのプラットフォームの運営を通じて流通情報に関する「通信の秘密」を知得する立場に立ち得るが、「通信」の行方を左右する伝送行為を直接担うわけではないため、電気通信事業者に比べ、憲法上の要請に拘束される度合いが弱く、他人間の情報のやり取りを実質的に媒介する限り通信の秘密を保護する義務を負うことに変わりはないものの、「アルゴリズム利用情報管理を通じて行う表現自体の自由」を相対的に広範に享有すると解される。

⇒介入禁止説や公益事業説の思想に全面的に依拠することは妥当ではない。

表現としてのアルゴリズム利用情報管理の憲法上の保護(3)

- ・ 伝統的なマスメディアが「編集」を通じて自らのメッセージの総合的な表出に従事してきたのと同様に、アルゴリズム利用情報管理も表現物の整理等を通じて一定の理解可能なメッセージを生み出す機能を有しているため、マスメディア区別説のように、アルゴリズム利用情報管理をマスメディアの編集機能と規範的に切り離すことも合理的でない。
- ・ もっとも、一般にジャーナリスト等の専門職能の判断に基づき行われるマスメディアの編集機能と、アルゴリズム利用情報管理を通じたプラットフォーム事業者の編集機能との相違に着目し、両者を規範的に区別する余地は皆無ではない。
- ・ しかし、判例が検索役務に関して「インターネット上の情報流通の基盤」（最決平成29年1月31日民集71巻1号63頁）と説くように、今や主要なプラットフォームは利用者の一次的な情報源等としての役割を果たしつつ表現の自由を支える重要な土台となっている。
- ・ それゆえ、プラットフォーム事業者の編集機能も、利用者の身近なオンライン上の表現の場において、流通情報の一次的なスクリーニングを行う役割を果たし得る。
- ・ すなわち、プラットフォーム上で発信された情報がその内容の真偽等を問わずに流通情報と化すことにより、思想の自由市場が歪められるおそれも生じ得る中で、プラットフォーム事業者の編集機能では行き届かない部分を中心に、マスメディアがこれを是正しないし補完することが期待される関係にある。

表現としてのアルゴリズム利用情報管理の憲法上の保護(4)

- ・このような思想の自由市場における相互補完的な役割にかんがみれば、マスメディアの編集機能とプラットフォーム事業者のそれとの区別は、両者の表現の自由の保障のあり方の分水嶺を画するほどの実体を伴ってはいない。
- ・それゆえ、マスメディアのみが「編集権」としての表現の自由を有し、プラットフォーム事業者はその限りではないと解するのは合理的ではない。
⇒マスメディア区別説について懐疑的。
- ・したがって、「プラットフォーム事業者がアルゴリズム利用情報管理を通じて行う表現の自由」が一定の範囲で保障されることを承認し、それに対する具体的な規制ないし統制のあり方について検討するという思考の道筋をたどることが妥当。
⇒支配者説の考え方に符合。
- ・支配者説は、プラットフォーム事業者がアルゴリズム利用情報管理を通じて行う表現（言論）の自由を正面から肯定しつつも、当該事業者が「支配者」として利用者とは異なる立場に立つことに着目し、かかる自由の全面的な行使を忌避しようとしているという点において、アルゴリズム利用情報管理の懸念要素を払拭又は緩和する可能性。

表現としてのアルゴリズム利用情報管理の憲法上の保護(5)

アルゴリズム利用情報管理に対して許容され得る規制の程度

- ・表現の自由の保障の核心は、表現の主体（表現者）がメッセージを表出する自由にある中で、アルゴリズム利用情報管理を通じた表現の主体はプラットフォーム事業者であるから、その具体的な行為に応じた（許容される規制の程度に関する）類型化が図られるべき。
- ・そこで、アルゴリズム利用情報管理（表現）自体に着目したアルゴリズム機能区別説の思想を援用する可能性が考えられる。
 - ⇒表現者としてのプラットフォーム事業者が設定するアルゴリズム利用情報管理の具体的な機能に応じて表現の自由の保障が及ぶ程度を典型的に区別する点において、表現の自由の核心を表出行為の保障と捉える思想に適合的。
- ・しかし、憲法との関係では、アルゴリズム機能区別説の思想をそのまま導入するのは困難。

【理由】

① 情報配置検索型管理における「編集」相当の要素が軽視されている。

- ・情報配置検索型管理は、流通情報の配置・検索だけでなく、それらに対する一定の意味づけを行っており、そこに「編集権」の行使の余地が認められる（例えば、検索役務を通じた検索結果は、特定の語句に対する検索要求に対して一定のウェブサイトをアクセスのしやすさと連動した「優先順位」をつけて表示することで、ある種の意味づけやコンセプト等を示す機能）。

表現としてのアルゴリズム利用情報管理の憲法上の保護(6)

② 憲法21条 1 項と同時に、同条 2 項後段の規定との関係についても考慮に入れる必要。

- ・プラットフォーム事業者は、個々の通信の秘密たる情報を直接取り扱う限り、当該秘密を侵害する行為は許容されないため、侵害に至らないと認められる範囲内で、アルゴリズム利用情報管理を通じて行う表現自体の自由の行使が許容されるにとどまる。

③ 利用者の表現の自由に関する法益との緊張関係が十分に考慮されていない。

- ・米国法上の議論では、言論選別型管理に対する規制よりも情報配置検索型管理に対する規制の方が許容される余地が大きいという帰結が導かれているが、憲法解釈論上は、利用者の法益との権衡上、前者の方が後者よりも許容される余地が大きいと考えられる。

アルゴリズム利用情報管理を通じた表現の自由の保障

- ・アルゴリズム機能区別説は、言論選別型管理の保護に重点をおくが、言論選別型管理は利用者の貴重な表現の機会を事実上剥奪するものにもなり得る。
- ・仮に言論選別型管理が野放図にされた場合、特定の独占的なプラットフォーム事業者により、各人のオンライン上の表現の自由のあり方が事実上決せられ、流通情報の取扱いに対する「私的権力」の濫用等の危険性も。

表現としてのアルゴリズム利用情報管理の憲法上の保護(7)

- ・プラットフォーム事業者は、各人のプラットフォームの利用に際して事実上の「支配者」としてその権限を行使し得る立場に立ち、利用者の表現の自由等に対する脅威となり得るため、憲法規範内在的な権衡上、言論選別型管理を通じて行う表現の自由の行使可能範囲は、部分的に縮減され得る。

※ ただし、利用者の表現物が他人の権利を侵害する場合には、言論選別型管理を通じた任意の削除等の行為も許容ないし促進され得る。

- ・仮に言論選別型管理が強固に保護される場合、その前提として、プラットフォーム事業者は自らの「アルゴリズム利用情報管理を通じた表現」に対して（選別対象の表現物が他人の権利を害するものであるか否かにかかわらず）常に法的責任を負うこととなる可能性があるが、これは、他人の権利を侵害する表現物の削除等を通じた「表現」を萎縮させ得る（法律上の枠組みにも適合しない）。

※ 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律（情報流通プラットフォーム対処法）に基づき、SNS運営者等のプラットフォーム事業者は、流通情報の削除を行った場合や行わなかった場合に、一定の範囲で免責される。

【参考】情報流通プラットフォーム対処法における主な規律（Ⅰ）

第3条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この項において「関係役務提供者」という。）は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、**次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。**ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。

- 一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
- 二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による**情報の送信を防止する措置を講じた場合**において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、**次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。**

- 一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
- 二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報等を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該申出に係る侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

※ 上記3条1項は**不作為責任**の範囲を、3条2項は**作為責任**の範囲を、それぞれ限定。

表現としてのアルゴリズム利用情報管理の憲法上の保護(8)

- ・ 情報配置検索型管理については、利用者の表現の自由に関する法益との衝突は比較的惹起しにくく、相対的に広範な自由の行使が予定されると考えられる。
- ・ 例えば、検索役務の検索結果において特定のウェブサイトの表示が削除されたとしても、当該ウェブサイトの作成者（表現者）の表現の機会自体が剥奪されるわけではない。表現物がプラットフォーム上から完全に消滅する場合に表現者の利益が害される度合いに比べれば、利用者の情報受領に関する利益が害される程度についても限定的。
- ・ 判例も、検索結果の表示に関して、「事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」の利用者による削除請求を認めるものの、それ以外の場合の当該請求には慎重な姿勢を示しており、当該表示の任意性に配慮している（前掲最決平成29年1月31日参照）。
- ・ ただし、情報配置検索型管理も利用者のプラットフォーム上の表現に一定の影響を及ぼし得るという性質に変わりはなく、各人の表現の自由等を過度に妨げないと認められる範囲内で正当に行行使可能となるという点では、言論選別型管理の場合と共通する。

表現としてのアルゴリズム利用情報管理の憲法上の保護(9)

- ・ 以上を総合すると、アルゴリズム利用情報管理を通じた表現の自由については、その行使可能範囲が国民各人の表現の自由等に関する法益を著しく害しないと認められる範囲内に縮減されるが、決して保障の程度が軒並み低くなるわけではない。
- ・ 言論選別型管理を通じて行使される自由に関しては、利用者の表現の自由等との権衡上、一般的な表現の自由に比べてその保護の程度が弱まる可能性が高い（自由の行使可能範囲が縮減される度合いが大きい）ものの、少なくとも情報配置検索型管理を通じて行使される自由に関しては、利用者の表現の自由等の行使に対する重大な支障とならない範囲内で、比較的広範に保障され得る。
- ・ 他方、アルゴリズム利用情報管理（言論選別型管理）を通じた表現の自由の行使は、利用者の表現の自由や通信の秘密等の基本権に対する直接的な制約（公権力による介入）を回避しつつ、プラットフォーム事業者の営為により問題となる流通情報をネットワーク空間上から円滑に排することに資する可能性も。

※ アルゴリズム利用情報管理を通じた表現の自由の保障は、それが適切な言論選別型管理を目的として行使される場合、発信者の匿名表現の自由をできる限り保障しつつ、他人の権利を侵害する表現物を効率的に排することを促進するための貴重な手段に。

⇒アルゴリズム利用情報管理（特に言論選別型管理）の具体的なあり方について、**立法を通じた統制**の実施が望ましい（**憲法21条2項後段の客観法的要請**として定位可能）。

【参考】情報流通プラットフォーム対処法における主な規律(2)

第27条 **大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。**この場合において、**当該基準は、当該送信防止措置を講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。**

- 一 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。
- 二 他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務（努力義務を除く。）がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。
- 三 緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。

2 大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。

- 一 **送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。**
- 二 役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。
- 三 発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。
- 四 送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。

3 大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。

4 第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

【参考】情報流通プラットフォーム対処法における主な規律（3）

第28条 **大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置（第二号及び次条第三号において「通知等の措置」という。）を講じなければならない。**この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。

- 一 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。
- 二 過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。

第31条 **総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項若しくは第三項、第二十八条又は第二十九条の規定に違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。**

- 2 **総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。**